

1529736-52.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... cometerem reiteradamente o crime de tráfico de drogas na Comunidade do Conde, nesta cidade.

No dia dos fatos, os acusados teriam exercido o tráfico ilícito de entorpecentes no local, tendo sido flagrados pelos policiais.

Policiais civis e militares realizavam a Operação Linha 17 na Comunidade do Conde, conhecida como ponto de venda de drogas. Ao perceberem a presença dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529736-52.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529736-52.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA e CLEITON GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas dos artigos 33, caput e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 e com o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque teriam, em local incerto, em data incerta, anteriormente ao dia 09 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de São Paulo, em plena vigência do estado de calamidade pública, em virtude do COVID 19, (Decreto estadual nº 64.879/2020), agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, se associado para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

Consta ainda que, no dia 09 de dezembro de 2021, às 12h30, na Rua José dos Santos Junior, 1, Viela (Casas Sem Nº) - Campo Belo, nesta cidade e Comarca de São Paulo, em plena vigência do estado de calamidade pública, em virtude do COVID 19, (Decreto estadual nº 64.879/2020), CLEITON GOMES DA SILVA e RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, teriam vendido, trazido consigo e guardado, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, grande montante

de drogas, consistente em 695 (seiscientos e noventa e cinco) pedras de crack, 124 (cento e vinte e quatro) pinos de cocaína, 137 (cento e trinta e sete) porções de maconha e 46 (quarenta e seis) porções de K2.

Segundo consta na denúncia, os acusados, em conluio entre si e demais indivíduos não identificados, teriam se associado para cometerem reiteradamente o crime de tráfico de drogas na Comunidade do Conde, nesta cidade.

No dia dos fatos, os acusados teriam exercido o tráfico ilícito de entorpecentes no local, tendo sido flagrados pelos policiais.

Policiais civis e militares realizavam a Operação Linha 17 na Comunidade do Conde, conhecida como ponto de venda de drogas. Ao perceberem a presença dos agentes, diversos indivíduos fugiram pelas vielas do local, sendo que dois deles teriam adentrado em um barraco vazio. Ao ingressarem no imóvel, policiais obtiveram êxito em deter e identificar o acusado RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, porém o segundo indivíduo teria tentado empreender fuga pela janela, mas foi detido e identificado como CLEITON GOMES DA SILVA.

Em revista pessoal, na posse de RODRIGO, foi encontrada uma pochete, a qual continha, em seu interior, 265 (duzentas e sessenta e cinco) pedras de crack com peso líquido de 90g, 94 (noventa e quatro) pinos de cocaína com peso líquido de 110g, 65 (sessenta e cinco) porções de maconha com peso líquido de 170g e 22 vinte e duas porções de K2, com peso líquido de 20g. Além da quantia de R\$ 2.162,00 (dois mil, cento e sessenta e dois reais) em dinheiro trocado.

Indagado informalmente, o acusado RODRIGO teria confessado a envolvimento no tráfico de drogas na comunidade, bem como indicado outro barraco utilizado para a guarda das drogas, no qual foram localizadas 430 pedras de crack com peso líquido de 270g, 72 (setenta e duas) porções de maconha com peso líquido de 190g, 30 (trinta) frascos plásticos com cocaína com peso líquido de 130g, e 24 (vinte e quatro) porções de K2 com peso líquido de 20g, além do valor de montante de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em cédulas diversas.

No chão da viela, foi localizada uma bolsa abandonada com 3 tijolos de maconha (2 inteiros e 1 pedaço) e 20 pedras de crack, não sendo identificado o responsável pela posse de tais entorpecentes

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em preventivas (fls. 132/137).

A denúncia foi oferecida às fls. 196/202.

A decisão de fls. 203/204 determinou a citação e notificação dos acusados, reservando desde logo data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 13h30.

Os réu foram citados (fls. 270 e 272). O réu CLEITON apresentou defesa prévia (fls. 241/ 260) por meio de advogado constituído (procuração a fls. 187). O réu RODRIGO também apresentou defesa prévia (fls. 230/239) por meio de advogado constituído (procuração a fls. 240).

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2.022 (fls. 276/278).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas arroladas Renato Saletti, Homero Eduardo Bueno Brito, Kyslley M. da Silva, Anderson José dos Santos, Karina Zacarias Barboni e Maria Ivoneide da Silva, tendo sido os réus interrogados ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, sem possibilidade de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada tendo em vista que, ambos registram condenações anteriores.

Já, a Defesa pugnou em alegações finais escritas (fls. 287/302 e fls. 304/324) pela absolvição dos acusados por falta de provas concludentes para a condenação, notadamente em relação à autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requereram a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Entorpecentes, afastamento da agravante da calamidade pública, concessão da forma privilegiada, reconhecimento da agravante da confissão plena (em relação ao réu Rodrigo), afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "J", do Código Penal, fixação de regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Ausentes questões preliminares, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/23), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 36/38), laudo de constatação (fls. 29/35), fotografias (fls. 39/41 e 147/148), laudo pericial definitivo (fls. 214/218), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, a demanda merece prosperar em parte. Vejamos.

O réu RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, em fase policial, alegou que: é comerciante, proprietário de uma adega juntamente com sua esposa; que, nesta data, deixou seu comércio e dirigiu-se para sua residência para almoçar; que, durante o trajeto, foi abordado por policiais militares, ocasião na qual, munidos de uma fotografia sua, informaram-lhe que havia um mandado de prisão em seu desfavor; que, na ocasião, não tinha nada de ilícito em seu poder; que, até então, desconhecia a existência de qualquer investigação de tráfico de drogas na qual fora citado; que, NEGA envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas ou quaisquer outros delitos; que, já fora processado criminalmente, anteriormente, contudo, "nada mais deve"; que, tem seis filhos e trabalha com o objetivo de sustentá-los; que, não conhece os demais indivíduos presos durante a operação policial; que, ostenta escoriações em sua face, resultantes de uma queda sofrida anteriormente.

Contudo, ouvido em Juízo, afirmou ser casado, ter seis filhos, ter estudado até a 5ª Série do Ensino Médio e, registrar condenação anterior pelo artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Quanto aos fatos, o réu se retratou, afirmando que trabalhava numa desentupidora, porém em razão da pandemia veio a sofrer sérios problemas financeiros e, há aproximadamente um mês retornou ao tráfico de drogas. Por fim, salientou que, as fotos acostadas aos autos (fls. 147/148) são realmente de sua pessoa, mas não conhecia a pessoa do corréu Cleiton, vindo a conhecê-lo apenas em decorrência da prisão deles em conjunto no dia dos fatos.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O réu CLEITON GOMES DA SILVA, na fase policial (fls. 07), alegou que: trabalha como entregador, há aproximadamente seis (6) meses; que, nesta data, dirigiu-se até uma adega para buscar mercadorias para sua patroa, adega essa situada na Rua José dos Santos Junior; que, ao chegar próximo à adega, notou que era realizada uma operação policial e, de repente, diversas pessoas começaram a correr; que, assustado, correu na mesma direção daquelas pessoas e, em dado momento, entrou em um barraco, cuja porta estava aberta; que, ali permaneceu por alguns poucos segundos e, por "não se sentir bem" naquele local, achou melhor dali se retirar e, ato contínuo, saiu por uma janela; que, já ao chegar na rua, foi surpreendido por policiais civis e detido; que, não fora localizado nada de ilícita em seu poder; que, ao ser indagado pelos policiais acerca do motivo pelo qual pulara a janela, disse que estava "assustado", negando, na ocasião, qualquer vínculo com o tráfico de drogas naquela região, razão pela qual, segundo soube, os policiais ali estavam; que, segundo os policiais, seria conduzido apenas para averiguação; que, não conhece nenhum dos outros indivíduos que foram presos nesta data durante a operação policial; que, NEGA veementemente o envolvimento com o tráfico de drogas; que, já fora processado uma vez, por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, contudo, "nada mais deve"; que, trabalha, atualmente, para sustentar seus três (3) filhos pequenos.

Ouvido em Juízo, o corréu reiterou a versão anteriormente apresentada durante a fase policial. Disse que é casado, possui três filhos menores, estudou até a 6ª Série e, já esteve preso anteriormente pelo crime de tráfico de entorpecentes, porém isso "faz mais de dez anos". Quanto aos fatos que ensejaram sua prisão, negou, de forma veemente, qualquer envolvimento no tráfico de drogas naquela região. Disse que trabalha como motoboy numa adega e, no dia 09 de dezembro de 2.021 foi

realizar uma entrega no local dos fatos, mas resolveu parar para comprar "uma paranga" de maconha para consumo próprio. Como viu aproximação dos policiais, não teve tempo hábil para adquirir o entorpecente, se assustou, correu e se escondeu. Quando pulou uma janela, acabou sendo abordado pelos milicianos na Avenida Roberto Marinho e, lhe disseram que seria levado apenas para "averiguação", mas acabou sendo envolvido, de forma equivocada, numa acusação de tráfico de drogas. A testemunha HOMERO EDUARDO BUENO BRITO, policial militar, em fase policial (fls. 02), relatou que: é componente do 5º BAEP/Barueri; que, nesta data, juntamente com outros policiais militares, participou da Operação denominada "Linha 17", desencadeada por esta Delegacia; que, durante incursão na Comunidade do Conde, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão temporária, deparou com diversos indivíduos em fuga pelas vielas daquele local; que, segundo pôde observar, mencionados indivíduos corriam na direção oposta da qual vinham policiais civis e, em dado momento, notou quando dois (2) desses adentraram em um barraco; que, juntamente com sua equipe, ingressou no imóvel, o qual estava vazio, desprovido de número de identificação, ocasião na qual surpreenderam ambos; que, enquanto um dos indivíduos fora contido, identificado como sendo o ora indiciado RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, um segundo, rapidamente, pulara pela janela do imóvel e empreendera fuga; que, no momento de sua abordagem, RODRIGO trazia consigo uma (1) pochete de cor preta, no interior da qual estavam acondicionadas duzentas e sessenta e cinco (265) pedras de crack, noventa e quatro (94) pinos de cocaína, sessenta e cinco (65) porções de maconha e vinte e duas (22) porções de K2; que, foram localizados em poder do indiciado, ainda, em um de seus bolsos, um (1) aparelho celular e o montante de R\$ 2.162,00 (dois mil, cento e sessenta e dois reais) em cédulas diversas; que, ao ser indagado, RODRIGO confessou a participação no tráfico de drogas na comunidade e, ato contínuo, indicou um outro barraco, também vago e sem número, utilizado para a guarda das drogas, imóvel no qual localizaram outra grande quantidade de drogas, quais sejam quatrocentas e trinta (430) pedras de crack, setenta e duas (72) porções de maconha, trinta (30) frascos plásticos com cocaína e vinte e quatro (24) porções de K2, bem como o montante de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em cédulas diversas; que, soube, posteriormente que, o outro indivíduo, o qual fugira pela janela, fora preso pelo policial civil testemunha RENATO; que, ante o exposto, deu voz de prisão em flagrante delito ao indiciado RODRIGO, cientificando-o quanto aos seus direitos, conduzindo-o, em seguida, a esta Delegacia.

Em juízo, a testemunha Homero afirmou que já existia investigação em andamento acerca de tráfico de drogas no local dos fatos, o que, inclusive, atrapalhava obra do Metrô junto ao Bairro de Campo Belo. No dia dos fatos, entrou na comunidade e, quando acessou uma determinada viela já se deparou com vários indivíduos correndo que, em dado momento, saíram de seu campo de visão. Posteriormente, viu que dois indivíduos entraram no mesmo "barraco". Quando ali ingressou, um deles (acusado CLEITON) pulou pela janela, vindo a saber posteriormente que foi capturado por policiais civis. Disse ainda que, capturou o corréu RODRIGO e, com ele foram encontradas várias porções de substâncias entorpecentes diversas, já devidamente acondicionadas, além do que, indicou aos policiais outro "barraco", também desabitado, onde mais porções de substâncias entorpecentes foram localizadas prontas para o consumo. Indagado, disse que os dois réus teriam corrido juntos para o mesmo local.

A testemunha RENATO SALETTI, policial civil, em fase policial (fls. 05), relatou que, na data dos fatos: foi um dos policiais responsáveis pela investigação que culminou na deflagração da operação policial realizada nesta data; que antes mesmo do início da ação policial, estivera na Comunidade do Conde e observara, à distância, um indivíduo, até então desconhecido, postado atrás de um buraco de um muro, local esse previamente identificado como local de venda de drogas; que, no decorrer das investigações, ainda durante a fase de observação antes do início da operação, mencionado indivíduo fora substituído por aquele já identificado durante as diligências, ora indiciado RODRIGO, contra o qual, inclusive, já havia sido expedido mandado de prisão temporária; que, com a incursão, já durante a operação propriamente dita, notou quando da evasão de alguns indivíduos, entre eles RODRIGO

e o desconhecido, ocasião na qual esses adentraram em um barraco, sendo, em seguida, perseguidos por policiais militares que participavam da operação; que, ao olhar para o chão da viela, localizou uma (1) pequena bolsa abandonada e, ao abri-la, constatou a existência em seu interior de três (3) tijolos da droga maconha (2 inteiros e 1 pedaço) e algumas pedras de crack, no total de vinte (20) unidades, não tendo observado o responsável por deixá-la naquele local; que, em ato contínuo, foi surpreendido com a saída de um dos indivíduos pela janela do barraco, no qual adentrara durante a fuga, sendo seguido por policiais militares e, rapidamente, procedeu à sua abordagem e prisão, ocasião na qual identificou-o como sendo CLEITON GOMES DA SILVA, indivíduo que, anteriormente, observara em companhia do indiciado RODRIGO no preparo das drogas para posterior venda; que, logo após, tomou conhecimento da prisão de RODRIGO, realizada pelo policial condutor e sua equipe, o qual fora surpreendido com drogas em seu poder, bem como quanto à localização de drogas em um outro barraco que esse indicara; que, ainda naquele local, o indiciado RODRIGO fora cientificado quanto ao teor do mandado expedido em seu desfavor. Em Juízo, o policial civil Renato salientou que participou da operação realizada pelo DENARC, juntamente com a Polícia Militar, a pedido do Governo do Estado de São Paulo. Segundo se recorda, já havia estado no local dos fatos, antes do dia 09 de dezembro de 2021, ocasião em que chegou até a fotografar o réu RODRIGO enquanto realizava a mercancia das drogas, que RODRIGO estava com mandado de prisão expedido e, acabou preso pela Polícia Militar na posse de substâncias entorpecentes. Já, o corréu CLEITON nunca apareceu nas fotografias retiradas durante o período de investigação da Polícia Civil, assim como não o conhecia antes dos fatos. Os dois acusados correram para os fundos da comunidade, sendo que, CLEITON pulou um muro e caiu quase que em cima de uma viatura policial, momento em que foi preso. Segundo a testemunha, durante o período em que permaneceu observando o movimento no local, viu alguns traficantes usando "balaclava", o que talvez impedisse o reconhecimento do corréu CLEITON, porque não se recordava de sua fisionomia. Mais uma vez, salientou que viu apenas RODRIGO nos dias anteriores à sua prisão praticando a venda de entorpecentes, ocasião em que foi até fotografado, bem como, requereram os policiais sua prisão. No dia dos fatos, não viu o réu CLEITON praticando nenhum ato de mercancia.

Todas as testemunhas arroladas pela Defesa e ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que conheciam CLEITON antes dos fatos, que o mesmo teve uma passagem anterior pela Justiça Criminal, mas isso ocorrera há mais de dez anos e, atualmente, cuida de seus filhos e trabalha como motoboy. Até sua empregadora, Sra. Maria Ivoneide disse que o mesmo no dia 09 de dezembro de 2021 estava trabalhando em sua mercearia quando foi realizar compras para ela numa outra adega e, não mais retornou.

Portanto, como se vê, as circunstâncias das prisões e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam os réus até o início da operação policial, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, configurando-se o crime de tráfico de entorpecente, porém, apenas em relação ao réu RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias das prisões e da apreensão, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Dessa forma, o conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do acusado RODRIGO que, inocentou o corréu CLEITON durante seu interrogatório judicial.

Ademais, presente a condição da traficância no local, pela própria quantidade e diversidade de drogas apreendidas, confirmadas pelo laudo de fls. 214/218, montante consistente em 218,1 gramas, no qual foi constatado a presença da substância

COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); um montante consistente em 1.906,8 gramas, no qual foi detectado a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020; além de um montante consistente em 6,6 gramas, no qual foi detectado a presença da substância ADB-BUTINACA, constante na Lista F2 por se enquadrar no item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos) subitem 6 (estrutura B10) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020), bem como pela quantia em dinheiro (R\$2.162,00), em cédulas de pequeno valor, sendo certo que, os policiais realizaram investigação em dias anteriores e, chegaram a fotografar o réu RODRIGO no local dos fatos (fls. 147/148), tudo devidamente ratificado em Juízo.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade e a diversidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade, a variedade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que foram apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porém apenas em relação ao réu RODRIGO, como anteriormente mencionamos.

Em relação ao corréu CLEITON, é fato que nenhuma substância entorpecente foi localizada em seu poder. Além disso, no dia de sua prisão, bem como nos dias anteriores, quando se realizou investigação policial no local, o mesmo não foi visto naquela localidade realizando qualquer atividade ligada ao tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, policiais não presenciaram qualquer atividade envolvendo a mercancia de entorpecentes por ele. Há divergência entre os próprios policiais que não souberam especificar com exatidão, se RODRIGO e CLEITON estavam juntos no momento da abordagem policial. Ao que tudo indica, eles correram juntos, segundo o depoimento do policial militar Homero, mas inúmeras outras pessoas também correram quando se iniciou a operação policial.

O único indício envolvendo CLEITON ao tráfico de entorpecentes é que, ele teria ingressado num "barraco", onde policiais encontraram uma mochila com entorpecentes em seu interior, bem como, tentou se evadir daquele local.

Ocorre que, a posse de todo entorpecente foi assumida pelo réu RODRIGO, que também informou ao Juízo que não conhecia a pessoa de CLEITON. E, a tentativa de fuga foi por CLEITON esclarecida em Juízo, quando afirmou que correu no momento da batida policial por sentir medo, o que não deixa de ser, de todo, inverossímil.

Dessa forma, os indícios probantes amealhados nestes autos, autorizam a condenação apenas do réu RODRIGO pelo delito tipificado no artigo 33, da Lei número 11.343/06, sendo, em contrapartida, parcos para ensejar a condenação do corréu CLEITON pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, sendo, de rigor, sua absolvição.

Quanto ao crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, relativo à associação para o tráfico, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu balizas para aferição de sua incidência, sustentando-se que, para a caracterização de tal crime, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo.

Ocorre que não restou configurado nos autos o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Não se logrou comprovar, por exemplo, uma estrutura de divisão de tarefas, com atividades atribuídas de modo permanente a cada um dos elementos e tampouco o vínculo duradouro entre eles, não restando devidamente comprovado nos autos que os acusados sequer se conheciam antes do dia da prisão.

Desta forma, pela não comprovação do caráter estável e permanente da associação, é o caso de absolvição quanto a este imputação, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

No que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta

que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Frise-se que RODRIGO apresenta maus antecedentes, conforme se depreende de fls. 97/103 e 113/115, pois já foi condenado pelos delitos de receptação e de tráfico de drogas. Assim e, tendo em vista que a grande quantidade de substâncias entorpecentes adquiridas em seu poder, indicam indícios de que esteja envolvido em organização criminosa, razão pela qual não fazem jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), não se tratando de mero traficante ocasional.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu RODRIGO, corroborada pela narrativa da pormenorizada dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência parcial da denúncia, condenando-se o acusado RODRIGO pelo crime tipificado no artigo 33, da Lei número 11.343/06.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu possui maus antecedentes (fls. 113/115), devendo incidir aumento de 1/6 (um sexto). Destaco que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 635.594, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021).

Culpabilidade, conduta social e personalidade não destoam do ordinário, não devendo ser valoradas.

Quanto às circunstâncias, motivos e consequências do crime também não há nada nos autos que evidenciem a necessidade de maior reprimenda.

Por fim, quanto à circunstância da quantidade e natureza das drogas, verifica-se que expressiva a quantidade de droga encontrada. O réu traficava elevada quantidade de drogas, com grande diversidade, especialmente, dentre outras, substância conhecida como "crack", que possui natureza altamente nociva, apta a gerar dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga. Desta forma, incide aumento de 1/5 (um quinto).

Fica a pena base, portanto, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu confessou, incidindo a atenuante tipificada pelo artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, devendo a pena base retornar ao mínimo legal.

Frise-se que, nos termos das certidões de fls. 113/115, embora portador de maus antecedentes, o réu não é reincidente.

Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "J", do Código Penal já foi afastada consoante fundamentação apresentada.

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias multa.

Torno definitivas as penas acima fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime

FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, inciso I e III, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, os réus não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, filho de Aristides Lopes de Oliveira e de Fátima Aparecida Pereira de Oliveira, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às respectivas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e, pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor unitário mínimo legal; absolvendo-o, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal da imputação de prática do crime tipificado no artigo 35, da Lei número 11.343/06; e absolvo CLEITON GOMES DA SILVA, filho de Expedito Porfírio da Silva e de Maria Gomes da Conceição, da imputação de prática do crime tipificado no artigo artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do réu RODRIGO no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de penas ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, os recursos em liberdade.

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Já, em relação ao réu CLEITON, diante de sua absolvição, determino expedição de alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandados de prisão e, tanto que verificados seus cumprimentos, expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido ao Funad (depósito às fls. 160/162), decretado seu perdimento em favor da União; d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido a fls. 36/38 em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição; e) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova f) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA